DATOS DEL PROCESO ARBITRAL

NRO. DE EXPEDIENTE : EXP. NRO. 08-2023-CEAS-CECARD/ARBITRAJE DE EMERGENCIA/ AYA.

MODALIDAD DE ARBITRAJE : Arbitraje de Emergencia.

PARTES INTERVINIENTES :

Demandante : Hydroconsulting Ingenieros Asociados S.R.L.

Demandado : Municipalidad Distrital de Totos.

ARBITRO DE EMERGENCIA : Abg. Carlos Enrique Álvarez solis.

SECRETARIA ARBITRAL : Bach. Katherine Sheyla Flores Martínez.

PEDIDO CAUTELAR : Medida Cautelar de No Innovar y otros.

FECHA DE INICIO : 28 de abril de 2023.

FECHA DE CONCLUSION : 16 de mayo de 2023.

Centro de Conciliación Arbitraje y Resolución de Disputas - CECARD

Ayacucho, 16 de mayo de 2023

RESOLUCIÓN DE ARBITRAJE DE EMERGENCIA N°05

VISTOS:

(i) Resolución de Arbitraje de Emergencia N°03.

(ii) El escrito sumillado como "***Solicito se dicte medida cautelar***", presentado por la empresa Hydroconsulting Ingenieros Asociados S.R.L.

(iii) El escrito sumillado como "***Respuesta a la Carta N°114-2023-SG-CARD-CECARD/AYA***", presentado por la Municipalidad Distrital de Totos.

(iv) El escrito sumillado como "***Escrito de aclaración sobre carta fianza de adelanto de materiales, conforme requerimiento en audiencia especial de arbitraje de emergencia***", presentado por la empresa Hydroconsulting Ingenieros Asociados S.R.L.

(v) El escrito sumillado como "***Adjunto copia de Carta Fianza por Fiel Cumplimiento***", presentado por la empresa Hydroconsulting Ingenieros Asociados S.R.L.

(vi) El escrito sumillado como "***Respuesta a la Carta N°147-2023-SG-CARD-CECARD/AYA***", presentado por la Municipalidad Distrital de Totos.

CONSIDERANDO:

A.- GENERALIDADES SOBRE EL ARBITRAJE DE EMERGENCIA.

1. El Arbitraje de Emergencia es un mecanismo del proceso arbitral que *tiene como finalidad la dación de medidas de emergencia previas a la interposición de una solicitud arbitral, es decir, con anterioridad al proceso arbitral, a efectos de garantizar la eficacia del laudo final o tutelar el derecho la parte solicitante*. Asimismo, las medidas que pueden solicitarse en esta vía con las llamadas medidas cautelares, mismas que se encuentran contempladas en nuestro ordenamiento jurídico, específicamente, aquellas descritas por el artículo 47° del Decreto Legislativo N°1071 – Decreto Legislativo que regula el arbitraje en el Perú (en adelante, Ley de Arbitraje).

2. En tal sentido, se debe señalar que el arbitraje de emergencia nace de la necesidad de una de las partes de poder garantizar la materia de la litis tramitada ante arbitraje, es decir, existe un vínculo totalmente directo entre la tramitación de medidas precautorias y un procedimiento arbitral de emergencia, en donde el

objeto es el mismo; el poder garantizar la materia del objeto de la controversia y que sea posible ejecutar un laudo en el futuro; pero que en su tramitación el arbitraje de emergencia resulta más efectivo y que incluso llega a tener más sentido en su objeto que una simple tramitación de medidas cautelares puesto que este se encuentra sujeto a la designación de árbitros que en muchos casos duran meses[1].

3. Este procedimiento arbitral nace a partir de la práctica internacional y ha generado gran influencia y utilidad en el arbitraje doméstico, un reciente estudio[2] comparativo sobre el sistema arbitral en México, Perú y Ecuador, ha señalado lo siguiente:

> *La experiencia latinoamericana demuestra que las instituciones arbitrales más importantes de México, Perú y Ecuador reconocen la necesidad de innovar y regular los procedimientos de árbitro de emergencia exigidos por la naturaleza misma del derecho, la realidad y las necesidades de los usuarios del arbitraje comercial internacional.*

4. Asimismo, una medida de emergencia es aquella que ordena un Árbitro de Emergencia previamente al inicio del arbitraje, a efectos de asegurar la eficacia de la decisión proveniente del Laudo Arbitral o evitar que por el solo paso del tiempo del proceso se genere un daño irreversible que afecte directamente a quien le corresponde el derecho. No obstante, estas medidas son, por naturaleza, temporales y *su continuidad están sujetas a que el solicitante interponga la Solicitud Arbitral en el plazo concedido por el Tribunal Arbitral.*

5. Asimismo, bajo el amparo de lo señalado y conforme a su derecho, mediante escrito de fecha 28 de abril de 2023, la empresa Hydroconsulting Ingenieros Asociados S.R.L. interpone el pedido de medida de emergencia mediante el escrito de vistos (ii) ante el Centro de Arbitraje y Resolución de Disputas – CECARD, contra la Municipalidad Provincial de Totos, en virtud del Contrato N°090-2022-MDT/GM para la contratación de la ejecución de la Obra: "*Mejoramiento y ampliación del servicio de agua del sistema de riego Piedra Blanca – Wichinka en el Centro Poblado de Chacabamba, distrito de Totos, provincia de Cangallo – Ayacucho"*, suscrito por ambas partes el 19 de julio de 2022; solicitando se dicte una medida cautelar consistente en:

(i) Ordenar a la Municipalidad Distrital de Totos, se abstenga de realizar cualquier acto que signifique, liquidar la Obra, ejecutar el saldo de la Obra

[1] Mamani, Arian; Arcos, Julio; & Holguin, Josselin. (15 de mayo de 2023). La primera perspectiva del árbitro de emergencia. Portal web Arbanza Escuela de Arbitraje. Recuperado de: https://arbanza.com/la-primera-perspectiva-del-arbitro-de-emergencia/.

[2] Salazar, Homero; Montserrat Abogado; Alfonzo, José Daniel; Alba, Raúl; & Escalona G., Jorge. (10 de mayo de 2023). *Arbitraje de Emergencia: Un análisis integral desde la perspectiva latinoamericana*. Portal web Arbanza Escuela de Arbitraje. Recuperado de: https://arbanza.com/arbitraje-de-emergencia-un-analisis-integral-desde-la-perspectiva-latinoamericana/.

por administración directa o por administración indirecta, mientras dure el proceso arbitral en curso.

(ii) Ordenar a MPFRE Perú, suspenda la ejecución de la Carta Fianza N°7102210101293-001 por Fiel Cumplimiento, por el importe de S/617,051.43 (Seiscientos Diecisiete Mil Cincuenta y Uno y 43/100 Soles), emitida a favor de la Municipalidad Distrital de Totos del Contrato N°090-2022-MDT/GM.

En consecuencia, se curse oficio a MAPFRE Perú, con domicilio en Av. 28 de Julio N°873, distrito de Miraflores, provincia y departamento de Lima.

6. Según el literal b) del numeral 1, del artículo 47° de la Ley de Arbitraje, se indica como medida cautelar, que puede entenderse como una de no innovar, que el Tribunal Arbitral ordene a una de las partes: "*Que adopte medidas para impedir algún daño actual o inminente o el menoscabo del proceso arbitral, o que se abstenga de llevar a cabo ciertos actos que probablemente ocasionarían dicho daño o menoscabo al proceso arbitral*" [Subrayado agregado]. Es decir, tienen como finalidad evitar que no se modifique la situación de las cosas hasta que pueda emitirse el Laudo Arbitral o, en su defecto, hasta que desaparezca el peligro.

7. La teoría cautelar reconoce tres presupuestos para la adopción de medidas cautelares, mismos que deberán ser materia de análisis por el Árbitro de Emergencia en la presente Resolución, estos requisitos son los siguientes: **i)** La **verosimilitud del derecho** (*fumus boni iuris*); **ii)** El **peligro en la demora** (*periculum in mora*); y, **iii)** La **razonabilidad o adecuación de la medida**. Por otro lado, la doctrina y la legislación peruana reconocen a la contracautela como un requisito adicional para la adopción de medidas cautelares, así se reconoce en el numeral 4, del artículo 610° del Código Procesal Civil, y en el numeral 1, del artículo 47° de la Ley de Arbitraje.

8. No obstante, previamente a dicho análisis y de acuerdo con el artículo 9° de las Reglas de Árbitro de Emergencia[3], corresponde al Árbitro de Emergencia pronunciarse sobre la *admisibilidad de la solicitud* y su *competencia* para ordenar la Medida de Emergencia, así como las *razones de su decisión*.

B.- RESPECTO A LA ADMISIBILIDAD DE LA SOLICITUD DE ARBITRAJE DE EMERGENCIA.

9. El artículo 1° de las Reglas de Árbitro de Emergencia regula los requisitos que debe cumplir la Solicitud, según el siguiente detalle:

[3] Anexo I del Reglamento de Arbitraje del CECARD: https://cecard.org/wp-content/uploads/2022/10/REGLAMENTO-DE-ARBITRAJE-CECARD-10-2022.pdf.

Artículo 1°. -
Solicitud
(…)
2. La Solicitud de medidas de emergencia debe contener:
a. La información de contacto de las partes y de sus representantes.
b. La medida cautelar o provisional que se solicita.
c. La razón o las razones por las cuales el solicitante requiere que se dicte medidas cautelares urgentes.
d. Una descripción breve de la controversia sometida o que ha de ser sometida a arbitraje.
e. Una copia del convenio arbitral sobre cuya base se ha de resolver la controversia y del contrato del cual deriva dicha controversia.

10. Para efectos de corroborar el cumplimiento de cada uno de los requisitos establecidos en las Reglas de Árbitro de Emergencia, se procede al análisis comparativo entre los requisitos y el escrito de Solicitud del Reglamento en los siguientes términos:

a) La información de contacto de las partes y de sus representantes.

Datos de la parte solicitante:

ANEXOS:
ORIGINAL DE SOLICITUD CAUTELAR Y SUS ANEXOS.

Esc. N°:01

SOLICITO SE DICTE MEDIDA CAUTELAR.

SEÑOR ARBITRO DE EMERGENCIA - CENTRO DE ARBITRAJE Y RESOLUCIÓN DE DISPUTAS - CECARD / AYACUCHO

HYDROCONSULTING INGENIEROS ASOCIADOS S.R.L., con RUC 20452698413, debidamente representado por su Apoderada TORRES RAMOS SUSSY, peruana identificada con DNI N° 10251120, con domicilio en la Mz. F Lte. 15 URB. JOSE ORTIZ VERGARA (Enace) Ayacucho – Huamanga – Ayacucho, correo electrónico hciasrl@gmail.com y sussytorresr@gmail.com, teléfono 066280625 y 949499781; ante usted me presento y digo:

CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA…

Datos de la Entidad:

2. **NOMBRE Y DOMICILIO DE LOS AFECTADOS CON LA MEDIDA CAUTELAR**

La presente medida afectará a:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TOTOS, PROVINCIA DE CANGALLO, REGIÓN AYACUCHO, con RUC 20143660169, con domicilio: Plaza principal S/N Distrito de Totos – Cangallo – Ayacucho, oficina de enlace, Asociación los licenciados Mz. C lote 13 tercer piso (referencia: intersección entre avenida Independencia con Av. Javier Pérez de Cuellar, una cuadra arriba del puente ENACE), representado por su ALCALDE el licenciado WILSON RETAMOZO GÁLVEZ.

b) La medida cautelar o provisional que se solicita.

3. **PRETENSIÓN CAUTELAR DE NO INNOVAR**

En protección del legítimo derecho de HYDROCONSULTING INGENIEROS ASOCIADOS S.R.L., en el proceso Arbitral en curso y al amparo del Art. 6° concordante con el Art. 8° del Reglamento de Arbitraje del Centro de Arbitraje y Resolución de Disputas – CECARD y el Art. 47 de la Ley General de Arbitraje, aprobado mediante Decreto Legislativo 1071; SOLICITO DICTE MEDIDA CAUTELAR CONSISTENTE EN:

- ORDENAR A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TOTOS, SE ABSTENGA DE REALIZAR CUALQUIER ACTO QUE SIGNIFIQUE, LIQUIDAR LA OBRA, EJECUTAR EL SALDO DE LA OBRA POR

  ADMINISTRACION DIRECTA O POR ADMINISTRACIÓN INDIRECTA, mientras dure el PROCESO ARBITRAL EN CURSO.

- ORDENAR A MAPFRE PERU, SUSPENDA LA EJECUCIÓN de la CARTA FIANZA N° 7102210101293-001 POR FIEL CUMPLIMIENTO, por el importe de S/. 617,051.43 (Seiscientos Diecisiete Mil Cincuenta y Uno y 43/100 Soles), emitida a favor de LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TOTOS del contrato N° 090-2022-MDT/GM.

  En consecuencia, se curse oficio a MAPFRE PERU, con domicilio en Av. 28 de Julio N° 873, Distrito de Miraflores, Provincia y Departamento de Lima.

c) La razón o las razones por las cuales el solicitante requiere que se dicte medidas cautelares urgentes.

5. **SUSTENTO FACTICO DE LA PRETENSIÓN CAUTELAR 1:**
LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TOTOS, SE ABSTENGA DE REALIZAR CUALQUIER ACTO QUE SIGNIFIQUE, LIQUIDAR LA OBRA, EJECUTAR EL SALDO DE LA OBRA POR ADMINISTRACION DIRECTA O POR ADMINISTRACIÓN INDIRECTA

ANTECEDENTES

5.1 la Municipalidad Distrital de Totos, convocó al procedimiento de selección de la LICITACIÓN PÚBLICA N°001-2022-MDT/CS, para la contratación de la ejecución de obra: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO PIEDRA BLANCA-WICHINKA, EN EL CENTRO POBLADO DE CHACABAMBA, DISTRITO DE TOTOS, CANGALLO-AYACUCHO", CUI 2317199.

6. **SUSTENTO FACTICO DE LA PRETENSIÓN CAUTELAR 2:**
LA ENTIDAD SUSPENDA LA EJECUCINÓN de la CARTA FIANZA N° 7102210101293-001 POR FIEL CUMPLIMIENTO.

ANTECEDENTES

6.1 la Municipalidad Distrital de Totos, convocó al procedimiento de selección de la LICITACIÓN PÚBLICA N°001-2022-MDT/CS, para la contratación de la ejecución de obra: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO PIEDRA BLANCA-WICHINKA, EN EL CENTRO POBLADO DE CHACABAMBA, DISTRITO DE TOTOS, CANGALLO-AYACUCHO", CUI 2317199.

d) Una descripción breve de la controversia sometida o que ha de ser sometida a arbitraje.

6. **SUSTENTO FACTICO DE LA PRETENSIÓN CAUTELAR 2:**
LA ENTIDAD SUSPENDA LA EJECUCINÓN de la CARTA FIANZA N° 7102210101293-001 POR FIEL CUMPLIMIENTO.

ANTECEDENTES

6.1 la Municipalidad Distrital de Totos, convocó al procedimiento de selección de la LICITACIÓN PÚBLICA N°001-2022-MDT/CS, para la contratación de la ejecución de obra: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO PIEDRA BLANCA-WICHINKA, EN EL CENTRO POBLADO DE CHACABAMBA, DISTRITO DE TOTOS, CANGALLO-AYACUCHO", CUI 2317199.

5. **SUSTENTO FACTICO DE LA PRETENSIÓN CAUTELAR 1:**
LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TOTOS, SE ABSTENGA DE REALIZAR CUALQUIER ACTO QUE SIGNIFIQUE, LIQUIDAR LA OBRA, EJECUTAR EL SALDO DE LA OBRA POR ADMINISTRACION DIRECTA O POR ADMINISTRACIÓN INDIRECTA

ANTECEDENTES

5.1 la Municipalidad Distrital de Totos, convocó al procedimiento de selección de la LICITACIÓN PÚBLICA N°001-2022-MDT/CS, para la contratación de la ejecución de obra: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO PIEDRA BLANCA-WICHINKA, EN EL CENTRO POBLADO DE CHACABAMBA, DISTRITO DE TOTOS, CANGALLO-AYACUCHO", CUI 2317199.

e) Una copia del convenio arbitral sobre cuya base se ha de resolver la controversia y del contrato del cual deriva dicha controversia.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TOTOS

Gestión 2019 - 2022

supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS[3]
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

11. En ese sentido, debe declararse que la Solicitud de Medida de Emergencia presentada por la empresa Hydroconsulting Ingenieros Asociados S.R.L. cumple con todos los requisitos consignados en el artículo 1° de las Reglas de Árbitro de Emergencia del Centro de Arbitraje.

C.- RESPECTO DE LA COMPETENCIA DEL ÁRBITRO DE EMERGENCIA PARA CONOCER LE MEDIDA DE EMERGENCIA SOLICITADA POR HYDORCONSULTING INGENIEROS ASOCIADOS S.R.L.

12. En virtud de la **CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS** del Contrato bajo análisis, las partes suscriben el convenio arbitral tipo a través del cual no han precisado el tipo de arbitraje y, menos aún, la institución arbitral a cargo de resolver las controversias surgidas entre las partes del presente arbitraje; en los siguientes términos del convenio arbitral:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TOTOS

Gestión 2019 - 2022

supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS[3]

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

13. En ese sentido, se precisa que la normatividad de contrataciones del Estado respecto del convenio arbitral ha estipulado mecanismos para suplir la falta de acuerdo de las partes respecto al tipo de arbitraje. En tal sentido, el numeral 2 del artículo 226° del Reglamento de la Ley de Contrataciones de Estado, regula lo siguiente:

> ***Artículo 226°. - Convenio arbitral***
> *(…)*
> *226.2. En los siguientes supuestos, el arbitraje es iniciado ante cualquier institución arbitral:*
> *a) Cuando no se ha incorporado un convenio arbitral expreso en el contrato.*
> *b) Cuando a pesar de haberse precisado en el convenio arbitral que el arbitraje es institucional no se ha designado a una institución arbitral determinada.*

c) Cuando, a pesar de no cumplirse con las condiciones establecidas en el numeral 225.3 del artículo 225, en el convenio arbitral se señala expresamente que el arbitraje es ad hoc.
d) Cuando en el convenio arbitral no se haya precisado el tipo de arbitraje.
e) Cuando en el convenio arbitral se encargue el arbitraje al SNA-OSCE en contravención a lo establecido en el Reglamento y en el Reglamento del SNA-OSCE.
f) Cuando se trate de controversias que se desprenden de órdenes de compra o de servicios derivadas del Acuerdo Marco, siempre que no se haya incorporado un convenio arbitral en las mismas.

14. A su vez, la institución arbitral referida contempla el arbitraje de emergencia como parte de los servicios a los que pueden acceder las partes del arbitraje por su solo sometimiento a los reglamentos del mismo, según se desprende del artículo 63° de su Reglamento de Arbitraje:

Artículo 63º.-
Medida Cautelar emitida por Árbitro de Emergencia
1. Hasta antes de la constitución del Tribunal Arbitral, cualquiera de las partes que requiera medidas cautelares urgentes puede solicitar que se inicie un procedimiento ante un árbitro de emergencia, quien conoce y resuelve la respectiva solicitud.
2. Las decisiones adoptadas por el Árbitro de Emergencia son vinculantes para las partes, quienes, por el hecho de haber sometido la controversia a arbitraje bajo el Reglamento, se obligan a cumplirlas sin demora.
3. Se extingue la competencia del Árbitro de Emergencia por la constitución del Tribunal Arbitral.
4. El derecho de las partes de recurrir a un Árbitro de Emergencia no impide que cualquiera de ellas pueda solicitar a la autoridad judicial competente que dicte medidas cautelares.

15. En ese sentido, es competencia del Consejo del Centro de Arbitraje la designación del Árbitro de Emergencia, según se puede leer del numeral 1, del artículo 3° de las Reglas de Árbitro de Emergencia:

Artículo 3º.-
Nombramiento
1. El Consejo nombra a un Árbitro de Emergencia seleccionado entre los que integran el Registro de Árbitros del Centro en el plazo de un (01) día luego de la recepción de la solicitud.

16. En ese sentido, el Consejo Superior de Arbitraje designó a **CARLOS ENRIQUE ALVAREZ SOLIS** como Árbitro de Emergencia para el presente proceso, mismo

que se encuentra adscrito a la nómina de árbitros del Centro de Arbitraje, según se aprecia[4]:

Centro de Arbitraje y Resolución de Disputas CECARD

NÓMINA DE ÁRBITROS

01	Álvarez Solis, Carlos Enrique.	RNA – OSCE
02.	Apaza Moncada, Carol Yanely.	RNA – OSCE
03.	Becerra Farfán, María Hilda.	RNA – OSCE
04.	Chipana Catalán, Jhoel Williams.	RNA – OSCE

17. En consecuencia, y en virtud del principio Kompetenz – Kompetenz, *el Árbitro de Emergencia declara su competencia para conocer la solicitud de medida de emergencia presentada por la empresa Hydroconsulting Ingenieros Asociados S.R.L.*, toda vez que se ha cumplido con el procedimiento establecido en las Reglas de Árbitro de Emergencia y de acuerdo con la normativa nacional aplicable.

D.- ANÁLISIS DE LOS PRESUPUESTOS CAUTELARES EN LA MEDIDA DE EMERGENCIA SOLICITADA POR HYDORCONSULTING INGENIEROS ASOCIADOS S.R.L.

18. Mediante el escrito de vistos (i), la empresa Hydroconsulting Ingenieros Asociados S.R.L., solicitó que se conceda en su favor medida cautelar de no innovar, según los siguientes términos:

> ***3. PRETENSIÓN CAUTELAR DE NO INNOVAR***
> *En protección del legítimo derecho de HYDROCONSULTING INGENIEROS ASOCIADOS S.R.L., en el proceso Arbitral en curso y al amparo del Art. 6° concordante con el Art. 8° del Reglamento de Arbitraje del Centro de Arbitraje y Resolución de Disputas – CECARD y el Art. 47 de la Ley General de Arbitraje, aprobada mediante Decreto Legislativo 1071; SOLICITO DICTE MEDIDA CAUTELAR CONSISTENTE EN:*
> - *ORDENAR A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TOTOS, SE ABSTENGA DE REALIZAR CUALQUIER ACTO QUE*

[4] Puede consultarse la nómina de árbitros de la institución arbitral en el portal web oficial de esta: https://cecard.org/arbitraje/.

SIGNIFIQUE, LIQUIDAR LA OBRA, EJECUTAR EL SALDO DE LA OBRA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA O POR ADMINISTACIÓN INDIRECTA, mientras dure el PROCESO ARBITRAL EN CURSO.

- *ORDENAR A MAPFRE PERU, SUSPENDA LA EJECUCION de la CARTA FIANZA N°7102210101293-001 POR FIEL CUMPLIMIENTO, por el importe de S/617,051.43 (Seiscientos Diecisiete Mil Cincuenta y Uno y 43/100 Soles), emitida a favor de LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TOTOS del Contrato N°090-2022-MDT/GM.*
  En consecuencia, se curse oficio a MAPFRE PERU, con domicilio en Av. 28 de Julio N°873, Distrito Miraflores, Provincia y Departamento de Lima.

19. Como hemos hecho mención anteriormente, corresponde realizar el análisis de los tres presupuestos fundamentales para la dación de medidas cautelares (verosimilitud en el derecho, peligro en la demora y adecuación de la medida). Adicionalmente, se evaluará el otorgamiento de la contracautela realizada por la empresa Hydroconsulting Ingenieros Asociados S.R.L., como requisito de las medidas cautelares, en atención a garantizar los eventuales daños que devengan de la misma si otorgada la medida de emergencia, no correspondiere la misma. Es decir, en atención a evitar al peligro de que la medida de emergencia se indebidamente otorgada, *toda vez que una medida de emergencia o cautelar siempre es otorgada bajo una probabilidad razonable pero nunca bajo certeza*.

20. Empero, se precisa que a continuación se analizarán los presupuestos de la teoría cautelar respecto de cada pedido cautelar formulado por la empresa solicitante, en atención a que se trata de dos pedidos diferentes.

21. En virtud de lo señalado, procedemos a realizar el análisis comprendiendo los medios probatorios ofrecidos por el solicitante y los argumentos desarrollados en los escritos de vistos.

C.1.- RESPECTO DEL PEDIDO CAUTELAR REFERIDO A ORDENAR A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TOTOS, SE ABSTENGA DE REALIZAR CUALQUIER ACTO QUE SIGNIFIQUE, LIQUIDAR LA OBRA, EJECUTAR EL SALDO DE LA OBRA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA O POR ADMINISTACIÓN INDIRECTA, MIENTRAS DURE EL PROCESO ARBITRAL EN CURSO.

22. Por lo tanto, a continuación, el Árbitro de Emergencia señala que no corresponde el otorgamiento de la presente medida cautelar de emergencia, siempre que, el pedido cautelar formulado por el contratista se encuentra fuera del ámbito de la competencia que delimita el convenio arbitral.

23. La Municipalidad Distrital de Totos comunicó al contratista la resolución del contrato por concepto de incumplimiento de obligaciones mediante la Carta Notarial N°001-2023-MDT-GM/RTM por una discordancia entre el avance de valorización acumulado de la obra, en concordancia con el numeral 5 del artículo 203° del Reglamento de Contrataciones del Estado, según se aprecia de la Resolución de Gerencia N°006-2023-MDT/GM de fecha 23 de febrero de 2023 adjunta a la citada Carta.

24. Sin embargo, se debe precisar que el pedido cautelar formulado por el contratista radica en que la orden que se deberá dictar sobre la Entidad radica en liquidar la Obra, ejecutar el saldo de la obra por administración directa o indirecta hasta que dure el proceso arbitral en curso; según lo ha expresado en el primer punto del petitorio cautelar contenido en el numeral 3 del escrito de vistos (ii).

25. Empero, es menester indicar que, el convenio arbitral al ser un pacto que excluye a las partes de la jurisdicción ordinaria, este únicamente puede limitarse a la relación contractual respecto de la cual se ha pactado este mecanismo de solución de controversias.

26. Evidentemente, cada contrato constituye una relación jurídica diferente en materia de contratación pública, por lo que, los alcances a los que deba referirse el convenio arbitral únicamente alcanzan a la relación jurídica que regula, es decir, a la que refiere el Contrato principal que contiene el citado convenio. En tal sentido, este depende de la celebración de un contrato principal del cual hayan surgido o puedan surgir controversias litigiosas. En tal sentido, Matheus López[5] ha indicado que una forma de nacimiento del convenio arbitral es a través de su perfeccionamiento unidocumental, el cual se suscribe con un documento independiente al contrato principal o como cláusula del contrato principal.

27. En efecto, el arbitraje es un mecanismo de solución de controversias, es decir, en el fondo viene a ser un instrumento procedimental que, depende de una relación jurídica prexistente. No podrían resolverse controversias de relaciones jurídicas que no existen, por ello mismo, el convenio arbitral se perfecciona a través del acuerdo de ambas partes para someterse a este fuero.

28. De hecho, la misma cláusula arbitral contenida en la Cláusula Décima Octava: Solución de Controversias, indica que el convenio arbitral se refiere a la ejecución del Contrato sub litis, según se lee:

[5] Matheus López, Carlos Alberto. (2017). *El convenio arbitral y sus particularidades*. Athina, Manual de Arbitraje. Análisis, comentarios y reflexiones al Decreto Legislativo N°1071, (13), p. 68.

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS[3]

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

29. Por lo tanto, la competencia del Árbitro de Emergencia deriva del convenio arbitral, el cual de circunscribe a la ejecución contractual del Contrato que lo contiene, ello en razón a que el mismo numeral 1 del artículo 13° de la Ley de Arbitraje, según se puede leer a continuación:

> ***Artículo 13.- Contenido y forma del convenio arbitral.***
> *1. El convenio arbitral es un acuerdo por el que las partes deciden someter a arbitraje todas las controversias o ciertas controversias que hayan surgido o puedan surgir entre ellas respecto de una* ***determinada relación jurídica contractual*** *o de otra naturaleza.*

30. En comentario a este artículo, Mario Castillo, Rita Sabroso, Jhoel Chipana y Laura Castro, brindan una definición de convenio arbitral que, en el mismo sentido, contempla la relación jurídica determinada como un requisito de su formación; según se lee a continuación:

> *En este contrato las partes se obligan inequívocamente a sustraerse de la jurisdicción del Estado para someterse a una jurisdicción privada determinada por ellas, con el fin de resolver un hipotético conflicto de intereses que pudieran suscitarse de* ***una relación jurídica existente entre ambas****, esto es, casi para todos los efectos de la vida diaria,* ***otro contrato del que el arbitral forma parte****.*

31. En normativa específica sobre contrataciones del Estado, el numeral 1 del artículo 223° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, establece también que los mecanismos de solución de controversias giran en torno a un contrato, el cual, se entiende es el contrato respecto del cual se ha pactado el convenio arbitral; según se lee:

> ***Artículo 223. Disposiciones generales***
> *223.1. Las controversias que surjan entre las partes sobre la ejecución, interpretación, resolución, inexistencia, ineficacia o invalidez* ***del contrato*** *se resuelven mediante conciliación, junta de resolución de disputas o arbitraje institucional, según corresponda y por acuerdo de las partes.*

32. Por lo tanto, el Árbitro de Emergencia, el cual, obtiene su competencia del convenio arbitral suscrito por ambas partes, únicamente podría pronunciarse respecto de la materia controvertida vinculada al Contrato N°090-2022-MDT/GM que se presenta como el contrato que contiene la relación jurídica principal del cual deriva el convenio arbitral.

33. Adicionalmente a ello, el mismos OSCE ha indicado que es una potestad de la Entidad poder contratar la ejecución del saldo de obra pendiente derivado de un contrato de obra resuelto, sin perjuicio de que la resolución del mismo se encuentre sometida a arbitraje; así lo expresó en la Opinión N°082-2018/DTN, según se lee:

> **3*. CONCLUSIONES***
> *3.1. Conforme a lo establecido en el artículo 138 del Reglamento, una Entidad puede contratar la ejecución del saldo de obra pendiente derivado de un contrato de obra resuelto, con alguno de los postores que participaron del procedimiento de selección del que devino dicho contrato;* ***sin perjuicio de que la resolución del mismo se encuentre sometida a arbitraje****.*

34. Sin embargo, cabe hacer la precisión que, pese a que la citada opinión de OSCE se emite en el marco de una normatividad no vigente, se debe precisar que el criterio de la ley sigue siendo el mismo, según se puede apreciar de la comparación efectuada a continuación de la norma derogada con la norma vigente:

DECRETO SUPREMO N°056-2017-EF **Decreto Supremo que modifica el Reglamento de la Ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo N°350-2015-EF**	**DECRETO SUPREMO N°344-2018-EF** **Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado**
Artículo 138.- Prestaciones pendientes en caso de resolución de contrato	***Artículo 167. Prestaciones pendientes en caso de resolución***

*138.1. Cuando se resuelva un contrato y exista la necesidad urgente de culminar con la ejecución de las prestaciones derivadas de este, **sin perjuicio de que dicha resolución se encuentre sometida a alguno de los medios de solución de controversias**, la Entidad puede contratar a alguno de los postores que participaron en el procedimiento de selección. Para estos efectos, la Entidad debe determinar el precio de dichas prestaciones, incluyendo todos los costos necesarios para su ejecución, debidamente sustentados.*	***de contrato o declaratoria de nulidad de contrato*** *167.1. Cuando se resuelva un contrato o se declare su nulidad y exista la necesidad urgente de continuar con la ejecución de las prestaciones derivadas de este, **sin perjuicio de que dicho acto se encuentre sometido a alguno de los medios de solución de controversias**, la Entidad puede contratar a alguno de los postores que participaron en el procedimiento de selección. Para estos efectos, la Entidad determina el precio de dichas prestaciones, incluyendo todos los costos necesarios para su ejecución, debidamente sustentados.*

35. Por lo tanto, se puede apreciar que el criterio normativo plasmado en la norma anterior, así como en la norma vigente es el mismo, por lo tanto, el criterio expresado por el OSCE resulta plenamente aplicable al Contrato sub litis, de conformidad a lo señalado por el Árbitro de Emergencia en la presente resolución.

36. En consecuencia, no siendo posible que este Árbitro de Emergencia se pronuncie sobre un nuevo procedimiento de selección, así como que la misma normatividad de contrataciones del Estado indica que la convocatoria puede realizarse sin perjuicio del sometimiento a arbitraje de la resolución contractual, no corresponde que este Árbitro de Emergencia, conceda el primer pedido cautelar formulado por la empresa Hydroconsulting Ingenieros Asociados S.R.L.

C.2.- RESPECTO DEL PEDIDO CAUTELAR DE ORDENAR A MAPFRE PERU, SUSPENDA LA EJECUCION DE LA CARTA FIANZA N°7102210101293-001 POR FIEL CUMPLIMIENTO, POR EL IMPORTE DE S/617,051.43 (SEISCIENTOS DIECISIETE MIL CINCUENTA Y UNO Y 43/100 SOLES), EMITIDA A FAVOR DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TOTOS DEL CONTRATO N°090-2022-MDT/GM. EN CONSECUENCIA, SE CURSE OFICIO A MAPFRE PERU, CON DOMICILIO EN AV. 28 DE JULIO N°873, DISTRITO MIRAFLORES, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA.

37. En segundo término, la empresa Hydroconsulting Ingenieros Asociados S.R.L., ha solicitado a este Árbitro de Emergencia conceder el segundo pedido cautelar

referente a ordenar a la empresa aseguradora la suspensión de la ejecución de la garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato N°090-2022-MDT/GM.

38. No obstante, al respecto, la Municipalidad Distrital de Totos, mediante lo expresado en el numeral 2.9. de su escrito de vistos (iii) decidió allanarse, o acogerse, al pedido cautelar formulado por el solicitante has terminar con la emisión del Laudo Arbitral correspondiente, según se aprecia:

2.8. Que, el estado a través de sus organismos busca solventar las necesidades de la sociedad, teniendo esta obra un carácter de necesidad publica bajo un orden constitucional por lo cual debe declararse **IMPROCEDENTE** la medida de ABSTENCION en contratar bajo administración directa o indirecta correspondientemente, **por no tener fundamento legal**, siendo que la Empresa HYDROCONSULTING INGENIEROS ASOCIADOS SR, en tiempo oportuno debió haber agotado las vías correspondientes en los plazos establecidos conforme a Ley.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TOTOS - CANGALLO - AYACUCHO - 2023 - V°B° GERENCIA MUNICIPAL

2.9. Que, con respecto a la pretensión de la SUSPENSION de la CARTA FIANZA, nos acogemos a poder seguir hasta terminar con la emisión de un Laudo Arbitral.

Por todo lo expuesto, al Árbitro de Emergencia solicito

39. Por lo tanto, al no concurrir una disputa jurídica y, por el contrario, un acuerdo de las partes para dictar la medida cautelar contenida en el segundo pedido cautelar de emergencia del demandante, resulta inoficioso la evaluación de los elementos de la teoría cautelar, siempre que, la misma Entidad está aceptando el dictado de la medida cautelar de no innovar.

40. En consecuencia, se concede el segundo pedido cautelar formulado por la empresa Hydroconsulting Ingenieros Asociados S.R.L., consistente en ordenar a MAPFRE PERU, suspenda la ejecución de la Carta Fianza N°7102210101293-001 por fiel cumplimiento, por el importe de S/617,051.43 (SEISCIENTOS DIECISIETE MIL CINCUENTA Y UNO Y 43/100 SOLES), emitida a favor de la Municipalidad Distrital de Totos del Contrato N°090-2022-MDT/GM. En consecuencia, se curse oficio a MAPFRE PERU, con domicilio en Av. 28 de Julio N°873, Distrito Miraflores, provincia y departamento de Lima.

E.- RESPECTO DE LA CONTRACAUTELA EN LA MEDIDA DE ARBITRAJE DE EMERGENCIA.

41. Respecto al pedido de garantía o contracautela respecto de la presente medida cautelar, se precisa que, según el pedido de la solicitante esta deba ser emitida como caución juratoria en favor de la Entidad, para lo cual, este Árbitro de Emergencia, en virtud del ejercicio de su facultad de ejercer control difuso sobre las normas emite el presente pronunciamiento.

42. Por lo tanto, mediante la presente resolución se procede a exponer los fundamentos por lo que se ejerce control difuso respecto del Decreto de Urgencia N°020-2020-PCM. Para lo cual, el Árbitro de Emergencia desarrollará sus argumentos siguiendo la estructura que se indica a continuación:

i) Sobre la facultad del Árbitro de Emergencia para ejercer control difuso sobre el artículo 8° del Decreto de Urgencia N°020-2020.

ii) Otras consideraciones sobre la constitucionalidad del artículo 8° del Decreto de Urgencia N°020-2020.

iii) Sobre la graduación de la garantía solicitada como contracautela.

43. Por lo tanto, a continuación, se procede al desarrollo de cada uno de estos acápites, con la finalidad de sustentar la decisión contenida en la presente Resolución.

E.1.- SOBRE LA FACULTAD DEL ÁRBITRO DE EMERGENCIA PARA EJERCER CONTROL DIFUSO SOBRE EL ARTÍCULO 8° DEL DECRETO DE URGENCIA N°020-2020.

44. El ordenamiento jurídico peruano es eminentemente de naturaleza romano-germánica, por lo cual, la ley escrita, cuerpos normativos o documentos legales, son la fuente de derecho principal del derecho peruano, por lo cual, es correcto indicar que no es encontramos frente a una especie de positivismo metodológico. En ese sentido, el ordenamiento jurídico necesita inspirarse en un sistema de jerarquización de normas, donde la norma suprema es la Constitución. El principio de supremacía constitucional puede ser entendido como la doctrina que ubica a la Constitución en el nivel normativo superior con la mayor jerarquía jurídica ubicando a este documento supralegal en la cabeza del ordenamiento jurídico del Estado. Esta supremacía implica que frente a una violación de la Constitución se haga efectiva su protección a través del control de constitucionalidad[6].

45. En el ordenamiento jurídico peruano el principio de supremacía constitucional se encuentra recogido en el artículo 51° de la Constitución en el cual se indica lo que sigue:

> ***Artículo 51°***
> *La Constitución prevalece sobre toda norma legal; la ley, sobre las normas de inferior jerarquía, y así sucesivamente. La publicidad es esencial para la vigencia de toda norma del Estado.*

[6] Salgado Pesantes, Hernán. (2003). *Lecciones de Derecho Constitucional*. Ediciones Abya-Yala, pp. 58 y 59.

46. Al respecto el Tribunal Constitucional ha señalado que según este principio todos los poderes constituidos están por debajo de la Constitución, de ahí que se pueda señalar que es la ley superior, y, por tanto, obliga por igual tanto a gobernantes como gobernados, incluida la administración pública, según se estableció en la Sentencia del Tribunal Constitucional recaída sobre el expediente N°0042-2004-AI. Por estos motivos las atribuciones jurisdiccionales, sea en sede judicial ordinaria, especial o cuasijurisdiccional administrativa, se encuentran vinculadas al principio jurídico de supremacía constitucional señalado en el artículo 51° de la Constitución, en sus dos vertientes: fuerza normativa positiva (aplicando las normas legales en base a las disposiciones constitucionales) y negativa (inaplicando la norma administrativa y/o legal que sea extraña a la Constitución), de conformidad a lo señalado en la STC N°0004-2006-AI[7].

47. En atención a este importante principio del derecho peruano, la Constitución ha previsto como mecanismo de protección constitucional el ejercicio de control difuso de parte de los órganos jurisdiccionales en la figura del control difuso, en palabras de Pedro Grández Castro[8], invocando lo expuesto por el Tribunal Constitucional, señala que el control difuso es un "poder deber", en un deber en cuando a que los jueces no pueden aplicar leyes que previamente juzgan que son inconstitucionales.

48. Sobre el particular, es importante recordar que el arbitraje o fuero arbitral, es reconocido por la Constitución como un órgano con función jurisdiccional, según se ha señalado en el numeral 1 de su artículo 139°, de igual forma según lo señalado por el mismo Tribunal Constitucional en la STC N°6167-2005-PHC/TC, según se puede leer:

> *Desde esta perspectiva, este Tribunal reconoce la jurisdicción del arbitraje y su plena y absoluta competencia para conocer y resolver las controversias sometidas al fuero arbitral, sobre materias de carácter disponible (…) con independencia jurisdiccional y, por tanto, sin intervención de ninguna autoridad, administrativa o judicial ordinaria.*

49. Sin embargo, este poder jurisdiccional implica más que la sola potestad de resolver controversias de forma autónoma, por lo cual, el tribunal arbitral deberá garantizar el cumplimiento de los principios que inspiran la tutela jurisdiccional efectiva y el debido proceso que atiende a las partes procesales, en la misma sentencia del Tribunal Constitucional se ha indicado que:

---

[7] Diálogo con la Jurisprudencia. (2006). *La Constitución en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Sentencias vinculadas con los artículos de la Constitución*. Gaceta Jurídica, pp. 388 y 389.

[8] Grández Castro, Pedro. (2022). *El control constitucional difuso y el control convencional: Algunos problemas de articulación*. Fondo Editorial del Poder Judicial del Perú, p. 65 y 66.

> *(…) La naturaleza de jurisdicción independiente del arbitraje, no significa que establezca el ejercicio de sus atribuciones con inobservancia de los principios constitucionales que informan la actividad de todo órgano que administra justicia, tales como el de independencia e imparcialidad de la función jurisdiccional, así como los principios y derechos de la función jurisdiccional. En particular, en tanto jurisdicción, no se encuentra exceptuada de observar directamente todas aquellas garantías que componen el derecho al debido proceso.*

50. Ello implica que la jurisdicción arbitral deba velar por el cumplimiento de los principios y preceptos constitucionales, incluso aquellos establecidos en precedentes vinculantes del Tribunal Constitucional, tal como lo ha mencionado el máximo intérprete de la Constitución en la STC N°1567-2006-PA/TC señalando que "(…) *en el marco de un proceso arbitral deben ser respetados los derechos fundamentales y las garantías procesales y sustanciales que componen el debido proceso. Del mismo modo, deben ser observados los preceptos y principios constitucionales, conforme a la interpretación de los mismos que resulte de las resoluciones del Tribunal Constitucional; así como los precedentes vinculantes y las sentencias normativas que emita este Colegiado, dada su condición de supremo intérprete de la Constitución".*

51. Habiendo revisado ampliamente la doctrina y jurisprudencia del Tribunal Constitucional respecto de la jurisdicción arbitral, como parte de los poderes que implica la función jurisdiccional el Tribunal Constitucional a través del precedente vinculante María Julia (STC N°00142-2011-PA/TC) ha establecido la facultad legítima y constitucional de los árbitros para ejercer control difuso, siempre que este posee las garantías de todo órgano jurisdiccional, incluso aquella a la que refiere el segundo párrafo del artículo 138° de la Constitución. Tan es así que, en el fundamento 25 del mencionado precedente, señala de forma expresa que: "*En tal sentido, de presentarse en un proceso arbitral una incompatibilidad entre una norma constitucional y una norma legal, los árbitros deben preferir la primera".*

52. Sin embargo, toda vez que la interpretación por parte del Tribunal Constitucional debe moderar la aplicación de las disposiciones constitucionales, se estableció el precedente vinculante a manera de regla para la aplicación del control difuso en la jurisdicción arbitral lo siguiente:

> *El control difuso de la jurisdicción arbitral <u>se rige por las disposiciones del artículo VI del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional</u> y la jurisprudencia vinculante dictada por este Tribunal Constitucional sobre el control difuso. <u>Sólo podrá ejercerse el control difuso de constitucionalidad sobre una norma aplicable al caso de la que dependa la validez del laudo arbitral, siempre que no sea posible obtener de ella una interpretación</u>*

conforme a la Constitución y además, se verifique la existencia de un perjuicio claro y directo respecto al derecho de alguna de las partes.

53. Del citado precedente vinculante, se puede advertir que el control difuso deberá realizarse de conformidad con las disposiciones del artículo VI del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional. Sin embargo, es necesario precisar que a la fecha en que se emitió el precedente vinculante María Julia se encontraba en vigencia el anterior Código Procesal Constitucional, sin embargo, mediante la promulgación y publicación de la Ley N°31307 entró en vigencia el Nuevo Código Procesal Constitucional en julio del año 2021. En ese sentido, el precedente deberá entenderse en concordancia con el nuevo texto del Código Procesal Constitucional, siendo que la regulación sobre control difuso ya no se encuentra en el artículo VI del Título Preliminar sino en su artículo VII, advirtiéndose las siguientes diferencias de su lectura.

CÓDIGO PROCESAL CONSTITUCIONAL	
Ley N°28237 – Derogado	**Ley N°31307 – Vigente**
Artículo VI. Control Difuso e Interpretación Constitucional Cuando exista incompatibilidad entre una norma constitucional y otra de inferior jerarquía, el Juez debe preferir la primera, siempre que ello sea relevante para resolver la controversia y no sea posible obtener una interpretación conforme a la Constitución. Los Jueces no pueden dejar de aplicar una norma cuya constitucionalidad haya sido confirmada en un proceso de inconstitucionalidad o en un proceso de acción popular. Los Jueces interpretan y aplican las leyes o toda norma con rango de ley y los reglamentos según los preceptos y principios constitucionales, conforme a la interpretación de los mismos que	**Artículo VII. Control difuso e interpretación constitucional** Cuando exista incompatibilidad entre la Constitución y otra norma de inferior jerarquía, el juez debe preferir la primera, siempre que ello sea relevante para resolver la controversia y no sea posible obtener una interpretación conforme a la Constitución. Los jueces no pueden dejar de aplicar una norma cuya constitucionalidad haya sido confirmada en un proceso de inconstitucionalidad o en un proceso de acción popular. Los jueces interpretan y aplican las leyes o toda norma con rango de ley y los reglamentos según los preceptos y principios constitucionales conforme a la interpretación que resulte de las

resulte de las resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional.	resoluciones del Tribunal Constitucional.

54. Como se puede advertir no existe una variación sustancial en el texto del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional en lo que refiere al control difuso, por lo que, la aplicación de este por parte del Árbitro de Emergencia deberá entenderse con la Ley N°31307 – Nuevo Código Procesal Constitucional.

55. Ahora bien, cabe resaltar que la regla establecida en el precedente María Julia establece ciertos criterios que serán necesarios evaluar para la procedencia del control difuso de parte del Árbitro de Emergencia, entiéndase los siguientes:

(i) De la aplicación de la norma depende la validez del laudo arbitral.

- En principio, con el ejercicio de este control difuso se pretende que no se aplique, en específico, el último párrafo del numeral 2 del artículo 8° del Decreto de Urgencia N°020-2020, el cual dispone lo que sigue:

> ***Artículo 8.- Competencia en la colaboración y control judicial.***
> *2. (...)*
> *En los casos en los que el Estado peruano es la parte afectada con la medida cautelar, se exige como contracautela la presentación de una fianza bancaria y/o patrimonial solidaria, incondicionada y de realización automática en favor de la entidad pública afectada, por el tiempo que dure el proceso arbitral. El monto de la contracautela lo establece el/la juez/a o el tribunal arbitral ante quien se solicita la medida cautelar, dicho monto no debe ser menor a la garantía de fiel cumplimiento. La ejecución de la carta fianza se establece conforme a lo resuelto por el/la juez/a o el tribunal arbitral, según corresponda.*

- El ámbito de aplicación material de la norma jurídica invocada y respecto de la cual se aplica control difuso es la constitución y forma de la garantía o contracautela cuando el Estado peruano es el sujeto procesal que soporta una medida cautelar. En otras palabras, esta norma debe ser interpretada en el marco jurídico-conceptual de las medidas cautelares en los arbitrajes en los que participa en el Estado.

- Bajo esa premisa, corresponde indicar que la contracautela, si bien existe divergencias teóricas respecto a ser considerada como un presupuesto de la teoría cautelar, es correcto señalar que se presenta como un elemento que debe estar presente en toda decisión del tribunal arbitral sobre medidas cautelares, tan

es así que incluso el numeral 1 del artículo 47° de la Ley de Arbitraje prevé la presentación de esta garantía en los términos que siguen: "*1. Una vez constituido, el tribunal arbitral, a petición de cualquiera de las partes, podrá adoptar las medidas cautelares que considere necesarias para garantizar la eficacia del laudo, pudiendo exigir las garantías que estime conveniente para asegurar el resarcimiento de los daños y perjuicios que pueda ocasionar la ejecución de la medida".* Por lo tanto, de la presentación o no de la contracautela exigida por el Árbitro de Emergencia llevaría al cese de los efectos de la medida cautelar siempre que esta se solicita en calidad de un requisito de la misma.

- Se debe considerar que la finalidad de las medidas cautelares es la de conseguir o asegurar la eficacia práctica de la sentencia, más que hacer justicia, contribuye a garantizar el eficaz funcionamiento de esta[9]. Incluso la misma Ley de Arbitraje en el citado numeral 1 del artículo 47° indica que estas se dictan con la finalidad de garantizar la eficacia del laudo. A mayor abundamiento, la doctrina manifiesta que las medidas cautelares siempre deben tender a garantizar la eficacia del futuro laudo y, naturalmente, en caso los tribunales arbitrales las dicten deben exigir las garantías respectivas[10].

- Por tanto, la presentación de una contracautela que obedece a una disposición inconstitucional conllevaría a que la medida cautelar sea ineficaz y, en tanto los fines de las medidas cautelares, incida directamente en la ejecutabilidad del Laudo Final que resuelva las controversias surgidas entre las partes, toda vez que existe el peligro que el Laudo sea inejecutable o se genere un perjuicio irreparable a la parte demandante.

- Ello en razón a que la medida cautelar concedida por el Árbitro de Emergencia es de tipo no innovativa y respecto de la carta fianza otorgada como garantía de fiel cumplimiento del Contrato sub litis, por lo que, la inobservancia de la contracautela conllevaría a un inminente peligro de ejecución de la misma siempre que las garantías que se otorgan en el marco de las contrataciones del Estado son de ejecución automática y sin expresión de causa, según se lee del numeral 2 del artículo 33° de la Ley de Contrataciones del Estado:

> *33.2 Las garantías que acepten las Entidades deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización automática en el país, al solo requerimiento de la respectiva Entidad, bajo responsabilidad de las empresas que las emiten.*

[9] Ledesma Narváez, Marianella. (2013). *Íbidem*, p. 490.

[10] Castillo Freyre, Mario; Sabroso Minaya, Rita; Chipana Catalán, Jhoel; & Castro Zapata, Laura. (2018). *Ídem*, p. 610.

Dichas empresas deben encontrarse bajo la supervisión directa de la Superintendencia de Banca y Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y deben estar autorizadas para emitir garantías; o estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú.

- La ejecución de la garantía de fiel cumplimiento conllevaría a la inejecución del laudo arbitral dado cuenta la previsión presupuestal que implicaría el pago del monto que, en su momento y de acuerdo a su criterio, pueda ordenar el Tribunal Arbitral sobre el fondo de la controversia. Por lo que, resulta desproporcional poner en riesgo la tutela del derecho del contratista cuando este puede ser tutelado a través de una medida cautelar.

- En conclusión, por los fundamentos expuestos en la presente, el Árbitro de Emergencia considera que la aplicación del segundo párrafo del numeral 2 del artículo 8° del Decreto de Urgencia N°020-2020 incide directamente en la validez del Laudo que se emita con posterioridad, incluso, afectando a la propia naturaleza procesal de las medidas cautelares, en cuanto estas tienen como objeto asegurar la eficacia del Laudo.

(ii) No es posible obtener una interpretación de la norma conforme a la Constitución.

- Ahora bien, habiendo determinado la estrecha vinculación entre la contracautela y la eficacia del Laudo, corresponde continuar con el análisis del siguiente presupuesto para el análisis del control difuso de la norma.

- Para ello, el Árbitro de Emergencia precisa que la interpretación que se desprende del segundo párrafo del numeral 2 del artículo 8° Decreto de Urgencia N°020-2020 resulta inconstitucional por las siguientes cuestiones.

- En principio, el numeral 3 del artículo 139° de la Constitución señala que es un principio de la función jurisdiccional la observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional; según se ha revisado con anterioridad esta observancia también alcanza al fuero arbitral en tanto ejerce jurisdicción.

- De forma concordante, el artículo I del Título Preliminar del Código Procesal Civil señala que toda persona tiene derecho a la tutela jurisdiccional efectiva para el ejercicio o defensa de sus derechos o intereses, con sujeción a un debido proceso. Sobre este particular, María Elena Guerra – Cerrón escribe que la tutela

jurisdiccional efectiva es un principio-norma y principio-regla, y derecho-deber, derivado de la Constitución y de las cartas supranacionales que reconocen derechos y garantías procesales[11]. Más adelante, en la misma obra, Omar Sumaria comenta que la "efectividad" que se añade en el Título Preliminar del Código Procesal Civil tiene que ver con una promesa en el sentido que en el texto constitucional este derecho se presenta de manera abierta y abstracta, siendo en realidad "efectiva" cuando esta se haga realidad[12]. Por lo que, se puede comprender que el objeto de la Constitución al regular la tutela jurisdiccional es que esta sea eficaz, dado que, de lo contrario, este derecho resultaría únicamente retórico.

- Ahora bien, el Tribunal Constitucional ha señalado que el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva es un derecho que se "contenedor" que se compone de una serie de garantías propias para el ejercicio de la tutela jurisdiccional, entre ellas el debido proceso, el principio de igualdad, derecho de motivación, entre otros[13]. Incluso ha señalado a la tutela cautelar como manifestación implícita del debido proceso mediante la STC N°0023-2006-PI/TC[14], otorgando tan importancia a esta que compromete incluso los cimientos democráticos de la sociedad peruana, al indicar lo siguiente:

> *Si bien la tutela cautelar no se encuentra contemplada expresamente en la Constitución. Sin embargo, dada su trascendencia en el aseguramiento provisional de los efectos de la decisión jurisdiccional definitiva y en la neutralización de los perjuicios irreparables que se podrían ocasionar por la duración del proceso, se constituye como una manifestación implícita del derecho al debido proceso, consagrado en el artículo 139 inciso 3), de la Constitución. No existiría debido proceso, ni Estado Constitucional de Derecho, ni democracia, si una vez resuelto un caso por la autoridad judicial, resulta de imposible cumplimiento la decisión adoptada por esta.*

- Para los efectos de esta argumentación centraremos nuestro análisis en el derecho de igualdad procesal que atiende a los

[11] Guerra-Cerrón, María Elena. (2020). El umbral en el Código Procesal Civil: El Título Preliminar. En Varios autores. *El Título Preliminar del Código Procesal Civil*, Instituto Pacífico. 45.

[12] Sumaria Benavente, Omar. (2002). La constitucionalización del proceso: El contenido del derecho a la tutela jurisdiccional y el debido proceso. Comentario a la Casación N°1971-2016 Tacna. *Ídem*, p.109.

[13] STC N°0004-2006-PI/TC, f.j. 8.

[14] División de Estudios Jurídicos de Gaceta Jurídica. (2020). *20 años de sentencias claves del Tribunal Constitucional. Tomo II*. Rosas Alcántara, Joel. (Coordinador). Gaceta Jurídica, p. 163.

litigantes de una controversia ante la ley, por lo que el Árbitro de Emergencia considera que el Decreto de Urgencia N°020-2020 favorece desproporcionada e injustificadamente al Estado en el trámite de pedidos cautelares en el marco de un arbitraje, según las consideraciones que se exponen a continuación.

- El principio de igualdad puede ser entendido como aquel que procura la igualdad ante la ley y de trato que son aplicables a cualquier ordenamiento que se precie de justo. Este principio requiere predisponer de un proceso jurisdiccional al que cualquier justiciable, cualquiera sea su condición, pueda libremente acceder y pretender con todas las prerrogativas al mismo e igualitario servicio de justicia de su eventual contradictorio[15].

- Para el caso que nos ocupa, la norma bajo análisis regula un clarísimo supuesto de desigualdad ante la ley y, en consecuencia, desigualdad procesal, siempre que ve un beneficio desproporcionado e injustificado en favor del Estado toda vez que el alto estándar para ofrecer una contracautela en los arbitrajes en los que participe el Estado es únicamente para los privados, según se lee expresamente de la referida norma:

> ***Artículo 8.- Competencia en la colaboración y control judicial.***
> *2. (...)*
> *<u>En los casos en los que el Estado peruano es la parte afectada con la medida cautelar</u>, se exige como contracautela la presentación de una fianza bancaria y/o patrimonial solidaria, incondicionada y de realización automática en favor de la entidad pública afectada, por el tiempo que dure el proceso arbitral (…).*

- La norma es clara al indicar que este requisito únicamente será exigible cuando sea el Estado peruano la parte afectada o que soporta la medida cautelar. En buena cuenta, si el Estado fuera la parte que solicitaría la medida cautelar podría ofrecer cualquier tipo de garantía, incluso la caución juratoria regulada en el tercer párrafo del artículo 613° del Código Procesal Civil y que consiste en la promesa de resarcir los daños que, eventualmente, general la medida cautelar. La pregunta es **<u>¿CUÁL ES EL FUNDAMENTO POR EL CUAL EL ESTADO NO OTORGA LAS GARANTÍAS DEL D.U. N°020-2020 CUANDO SEA ESTE QUIEN SOLICITE LA MEDIDA CAUTELAR?</u>** No existe una respuesta para esta regulación, *máxime*, si la tutela jurisdiccional efectiva y el debido proceso deben implicar la

[15] Yedro, Jorgelina. (2012). Principios Procesales. En *Derecho & Sociedad*, (38), p. 272.

igualdad ante la ley además de ser garantizadas por el órgano jurisdiccional.

- En consecuencia, a consideración del Árbitro de Emergencia existe una clara desproporcionalidad en la regulación de las medidas cautelares solicitadas por un privado o por el Estado. Por lo que, esta situación regulada en el último párrafo del numeral 2 del artículo 8° el Decreto de Urgencia N°020-2020 contraviene directamente la Constitución en el extremo de la observancia debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva toda vez que transgrede la igualdad ante la ley.

- Se debe señalar que la garantía regulada en el Decreto de Urgencia N°020-2020 no hace ninguna diferencia con los otros tipos de contracautela permitidos por el ordenamiento jurídico peruano. Si bien es cierto, la dación de una medida cautelar pone en una situación de desequilibrio a una de las partes, no es menos cierto que la contracautela en cualquiera de sus formas sirve, precisamente para corregir esta situación por su propia definición. Sobre esto la doctrina ha indicado[16]:

> *Eso significa en derecho procesal la contracautela para garantizar la eficacia, para asegurar el resarcimiento de los daños y perjuicios que pudieran generarse para la parte que sufre o padece la medida cautelar, precisamente, si es que el laudo no termina dando la razón a aquella parte que solicita la medida cautelar.*
> *(…) Por ello, quien solicita una medida cautelar debe ofrecer una garantía a fin de resarcir los probables daños que ésta ocasione en el caso de que la pretensión principal sea desamparada. A esa garantía se le denomina contracautela. Simons menciona que la doctrina a desarrollado tres tipos de contracautela:*
> *Personal: representada por la fianza judicial.*
> *Real: representada a través de la obligación de bienes.*
> *Juratoria: representada por la prestación de un juramento.*

- Incluso la ex magistrada del Tribunal Constitucional Marianella Ledesma enseña que la contracautela *cumple la función de equilibrar las posiciones de las partes en el proceso evitando las consecuencias perjudiciales de una actuación procesal ilegítima*. Además – agrega – se trata de un remedio legal, puesto a disposición de una de las partes del proceso para evitar que la

[16] Castillo Freyre, Mario; Sabroso Minaya, Rita; Chipana Catalán, Jhoel; & Castro Zapata, Laura. (2018). *Ídem*, p. 611.

apariencia de un derecho, confirmado posteriormente como "infundado", se la causante de una serie de consecuencias lesivas en su patrimonio[17].

- Por lo tanto, la caución juratoria, al ser una forma de contracautela legal en el ordenamiento jurídico peruano y reconocida por la doctrina, cumple la misma función que la Entidad atribuye a la garantía prevista en el Decreto de Urgencia N°020-2020, es decir, la de equilibrar el *statu quo* de las partes en el marco del arbitraje. Generando que la interpretación de la norma que se somete a control difuso no encuentre justificación que sustente la desigualdad en la contracautela que deba ofrecer un privado respecto del Estado y la que pueda ofrecer el Estado, con total libertad vale decir, respecto de un privado.

- Al respecto, este Árbitro de Emergencia considera que se configuraría un supuesto de garantía sobre garantía o doble garantía, siempre que, el literal b) del numeral 1 del artículo 155° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado es claro al indicar que mientras no se declare el consentimiento de la resolución contractual no puede ejecutarse la garantía de fiel cumplimiento:

> *b) La garantía de fiel cumplimiento se ejecuta, en su totalidad, cuando la resolución por la cual la Entidad resuelve el contrato por causa imputable al contratista haya quedado consentida o cuando por laudo arbitral se declare procedente la decisión de resolver el contrato. En estos supuestos, el monto de la garantía corresponde íntegramente a la Entidad, independientemente de la cuantificación del daño efectivamente irrogado.*

- Muy por el contrario, la normatividad de la materia señala que esta deberá mantenerse vigente hasta la conformidad de la recepción de la prestación, o hasta el consentimiento de la liquidación final, según corresponda, de conformidad con el numeral 1 del artículo 149° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, según se lee:

> ***Artículo 149. Garantía de fiel cumplimiento***
> *149.1. Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador entrega a la Entidad la garantía de fi el cumplimiento del mismo por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta la conformidad de la recepción de la prestación a cargo del contratista, en el caso de*

[17] Ledesma Narváez, Marianella. (2013). *Ídem*, p. 109.

bienes, servicios en general y consultorías en general, o hasta el consentimiento de la liquidación final, en el caso de ejecución y consultoría de obras.

- En atención a estas consideraciones, el Árbitro de Emergencia no considera que exista otra forma de interpretación del último párrafo del numeral 2 del artículo 8° del Decreto de Urgencia N°020-2020, siendo que este contraviene abiertamente la Constitución, según lo expuesto anteriormente.

(iii) Se verifica la existencia de un perjuicio claro y directo respecto al derecho de alguna de las partes.

- En concierto con los fundamentos expuestos hasta extremo se puede advertir que la norma inconstitucional que contiene el Decreto de Urgencia N°020-2002 generaría un perjuicio claro y directo al demandante en atención al arbitraje seguido contra la Municipalidad Distrital de Totos.

- El perjuicio resulta ser claro siempre que no es necesario una interpretación sofisticada de la norma bajo control constitucional para advertir la desigualdad que esta contempla respecto a la exigencia de una contracautela desproporcionada que debe otorgar el privado que solicita una medida cautelar en perjuicio del Estado peruano.

- En ese sentido, se confirma la configuración de este presupuesto para ejercer el control difuso sobre la norma jurídica indicado, como se ha realizado en los argumentos previos.

56. Por las razones expuestas en el presente acápite el Árbitro de Emergencia ejercita control difuso respecto del último párrafo del numeral 2 del artículo 8° del Decreto de Urgencia N°020-2020, en razón a que deviene en inconstitucional, por lo que prescindir de su aplicación para el caso en concreto por los argumentos brindados anteriormente de conformidad a los presupuestos establecidos en el precedente vinculante María Julia establecido por el Tribunal Constitucional (STC N°00142-2011-PA/TC).

E.2.- OTRAS CONSIDERACIONES SOBRE LA CONSTITUCIONALIDAD DEL ARTÍCULO 8° DEL DECRETO DE URGENCIA N°020-2020.

57. Adicionalmente a los argumentos esbozados con anterioridad, el Árbitro de Emergencia señala argumentos que, a mayor abundamiento, permitirán entender las razones de su decisión para inaplicar el último párrafo del numeral 2 del artículo 8° del Decreto de Urgencia N°020-2020 en el presente caso.

58. En principio, corresponde señalar que la postura sobre inconstitucionalidad, o por lo menos cuestionamientos sobre la constitucionalidad, del último párrafo del

numeral 2 del artículo 8° del Decreto de Urgencia N°020-2020 es una posición unánime en la doctrina altamente difundida desde su promulgación. Distintos profesionales, académicos, litigantes y docentes han cuestionado este dispositivo legal a través de múltiples argumentos que recojo en la presente resolución para consideración en la motivación de la presente:

"Cuando el remedio no alivia la enfermedad: el Decreto de Urgencia 020-2020 y la propuesta de su derogación" artículo escrito por Carmela Ayllón[18]

> ***b. Inclusión de la fianza bancaria como contracautela***
> *Se ha modificado el artículo el artículo 8 de la Ley de Arbitraje, que regula la competencia en la colaboración y control judicial, y se ha establecido que, en los procesos en los que el Estado sea la parte afectada con la medida cautelar, se exigirá a la parte que la interponga, como contracautela, que presente una fianza bancaria y/o patrimonial solidaria e incondicionada, la cual deberá ser de realización automática a favor de la entidad correspondiente y deberá estar vigente durante el proceso (Decreto de Urgencia N.º 020-2020, 2020).*
> *Ahora bien, según el artículo 613 del Texto Único Ordenado de nuestro Código Procesal Civil, la contracautela es una medida que tiene como objeto salvaguardar al afectado (en este caso, el Estado) por los daños y perjuicios que pudiera ocasionarle la ejecución de la medida cautelar. En atención a ello, la referida normativa encomienda al juez la potestad de admitirla y fijar el monto de la misma, el cual podrá ser mayor o menor que el propuesto por el solicitante, considerando las particularidades del caso (Resolución Ministerial N°. 010-93-JUS, 1993).*
> *Sin embargo, el Decreto de Urgencia ha establecido que el monto de la contracautela no podrá ser menor al de la garantía de fiel cumplimiento del contrato en cuestión (la cual, por regla general, equivale al 10% del monto del mismo), con lo cual se ha prefijado un mínimo –nada modesto- que no necesariamente va a ser coherente con la afectación ocasionada. Ello configura una limitación al derecho al acceso a la tutela cautelar, dado que la contracautela es un requisito fundamental para que se admita la solicitud de la medida (Campos, 2020).*
> *Además, esta disposición aumenta la cuestionable desproporción a favor del Estado en el marco de estos procesos, sobre todo si se considera que este queda indemne ante dicha exigencia y su eventual limitación. Es una situación que ha sido observada en doctrina por diversos autores, tales como Horna (2020), Campos (2020), entre otros.*

"La libertad de los árbitros para fijar la contracautela en los procesos arbitrales en los que el Estado es parte" artículo escrito por Héctor Campos García[19]

> ***2. La regulación arbitraria de la contracautela y la limitación del derecho a la tutela cautelar en el DU***
> *Esta modificación, hay que decirlo, no reconoce justificación alguna. La contracautela es una garantía del derecho de crédito, eventual y determinable, derivado del reconocimiento de la responsabilidad civil por los daños derivados de la ejecución de una medida cautelar (para un estudio introductorio de la contracautela: Campos, 2015, pp. 165-213). Predeterminar el monto de la*

[18] Ayllón, Carmela. (15 de abril de 2021). *Cuando el remedio no alivia la enfermedad: el Decreto de Urgencia 020-2020 y la propuesta de su derogación*. Portal Jurídico IUS 360°. Recuperado de: https://ius360.com/cuando-el-remedio-no-alivia-la-enfermedad-el-decreto-de-urgencia-020-2020-y-la-propuesta-de-su-derogacion-carmela-ayllon/.

[19] Campos García, Héctor. (19 de febrero de 2020). *La libertad de los árbitros para fijar la contracautela en los procesos arbitrales en los que el Estado es parte.* Portal Jurídico LP Pasión por el Derecho. Recuperado de: https://lpderecho.pe/libertad-arbitros-fijar-contracautela-procesos-arbitrales-estado-parte/.

contracautela, de forma general y abstracta, sin atender a los criterios que existen para su cuantificación es un proceder arbitrario por parte del legislador que conlleva, además, una limitación al derecho a la tutela cautelar, en tanto la contracautela es una condición de eficacia de la resolución que concede la medida cautelar.
Por ello, esta disposición normativa ha sido especialmente criticada, entre otras, por las siguientes razones: (i) por el desequilibrio generado entre el Estado y su contraparte en el proceso ante el diferente tratamiento de los requisitos para que se ejecute una medida cautelar (Horna, 2020; Vidal, 2020) y (ii) por lo irrazonable que resulta la exigencia de una contracautela con una forma y un monto predeterminado en todo caso, sin atender a las circunstancias del caso concreto (Horna 2020; Soria, 2020).
Las críticas mencionadas son atendibles; por ello considero importante delimitar el ámbito de actuación de la modificación normativa con la finalidad de no generalizar una regla que, desde mi punto de vista, es del todo particular, por lo que propongo realizar una interpretación restrictiva de este extremo del DU que, en la medida de lo posible, no expanda los alcances de la modificación en materia de contracautela.

"A propósito del Decreto de Urgencia 020-2020: Paranoia Estatal o Necesidad Normativa" artículo escrito por Sergio Tafur Scaglia[20]

Conclusiones:
Más allá de si entendemos que la emisión de la presente norma constituye una decisión apresurada del Estado en atención a la coyuntura política nacional, consideramos que el Estado no ha dejado de ver al arbitraje con ojos de clientelismo, olvidándose de que en el arbitraje las partes son iguales sin importar las condiciones y que en el proceso, el Estado es una parte más.
Asimismo, es importante destacar que el Estado sigue considerándose un gestor de normas para proteger sus intereses, a toda costa, sin considerar que eventualmente puede vulnerar derechos constitucionales como el de libertad de contratación, más aún cuando está entrando en una norma de carácter eminentemente privado que no regula en sí mismo al Estado como parte en los arbitrajes, puesto que para ello tenemos otras normas especiales.
Así, en el presente supuesto el Estado no hace más que confundir a los postores y contratistas (en su mayoría inversionistas extranjeros) despojándolos de seguridad jurídica al dejar una incógnita respecto a la aplicación de las modificaciones y su entrada en vigencia y generando mayores dudas en la interpretación de los artículos modificados y en su aplicación. De allí que se diga que la implementación de decreto de urgencia que aparentemente puede tener un fin loable para la protección del interés estatal puede ser un remedio peor que la propia enfermedad.

"La arbitrariedad como regla: comentarios acerca de la inconstitucionalidad del artículo 8° del Decreto de Urgencia N°020-2020 | Ruinas en construcción" artículo escrito por Leandro García y Lorena Gamarra[21]

IV. CONCLUSIÓN

[20] Tafur Scaglia, Sergio. (27 de enero de 2020). A propósito del Decreto de Urgencia 020-2020: Paranoia Estatal o Necesidad Normativa. Portal jurídico Agnitio. Recuperado de: https://agnitio.pe/2020/01/27/a-proposito-del-decreto-de-urgencia-020-2020-paranoia-estatal-o-necesidad-normativa/.

[21] García, Leandro & Gamarra, Lorena. (14 de noviembre de 2020). *La arbitrariedad como regla: comentarios acerca de la inconstitucionalidad del artículo 8° del Decreto de Urgencia N°020-2020 | Ruinas en construcción*. Portal jurídico IUS 360°. Recuperado de: https://ius360.com/la-arbitrariedad-como-regla-comentarios-acerca-de-la-inconstitucionalidad-del-articulo-8-del-decreto-de-urgencia-n020-2020-ruinas-en-construccion/.

El artículo 8° del Decreto de Urgencia N° 020-2020 es inconstitucional porque colisiona de manera indebida y sin fundamento alguno los derechos a la tutela cautelar e igualdad procesal. En ese sentido, es necesario que en los casos que corresponda, los jueces y árbitros lo inapliquen a través del control difuso, en concordancia con lo establecido en el artículo 138° de la Constitución.

"Comentarios y críticas al DU 20/2020 que modifica la Ley de Arbitraje. La reserva mental del legislador y lo que realmente se normativizó" artículo escrito por Giusseppi Vera Vásquez[22]

II. La exigencia de contracautela por carta fianza no menor a la garantía de fiel cumplimiento cuando la medida cautelar es contra el Estado

La contracautela obedece a la necesidad de resarcimiento con ocasión de la responsabilidad civil por el daño que se pueda ocasionar con la dación y ejecución de la medida cautelar; por consiguiente, no es posible en abstracto, sin saber de qué pedido cautelar se trate, imponer que la contracautela, en modo carta fianza, no sea menor al monto de la garantía de fiel cumplimiento. La norma es arbitraria y no resiste argumento técnico que permita entender la razón por la cual exista este beneficio a favor del Estado.

En tanto la contracautela es un requisito para el otorgamiento de la medida cautelar, constituye un gravísimo atentado al derecho a ejercitar la tutela cautelar, la imposición del requisito arbitrario que se comenta. Más, si debe entenderse a la tutela cautelar como parte del elenco de derechos comprendidos en el derecho constitucional a la tutela efectiva. Evidentemente la medida significa un grave desequilibrio en las reglas de juego, siendo sumamente oneroso el requerimiento para el contratista mientras que para el Estado no lo es.

La arbitraria disposición no tiene en cuenta el perjuicio económico que significa para el Estado la implementación de la contracautela y quantum mínimo previsto por el DU en un escenario en que el laudo favorezca al contratista. El Estado deberá pagar los costos de financiamiento y mantenimiento tanto de la carta fianza por la garantía de fiel cumplimiento del contrato así como también respecto de la carta de fianza que se necesitó emitir como contracautela, amén de la posibilidad que también se pueda demandar por la pérdida de oportunidad ante la imposibilidad de utilizar dicha garantía para otro propósito del giro empresarial.

59. Por lo tanto, habiendo transcrito el criterio y opinión técnica de distintos colegas en materia arbitral y de contrataciones del Estado, es correcto señalar que las disposiciones que contiene el último párrafo del artículo 8° del Decreto de Urgencia N°020-2020 ha sido arduamente cuestionado por la doctrina peruana señalando esta norma como inconstitucional, por lo que el criterio del Árbitro de Emergencia no es un criterio aislado a la interpretación de dicha norma, sino que representa la opinión de la doctrina mayoritaria y de la mayoría de operadores jurídicos que atraviesan problemas a raíz del referido decreto de urgencia.

60. Por último, un argumento final respecto del cual es importante pronunciarse en la presente resolución es el referido a la revisión que hiciera el Congreso de la República sobre el Decreto de Urgencia N°020-2020, en el cual señaló lo que sigue:

[22] Vera Vásquez, Giusseppi. (23 de diciembre de 2020). *Comentarios y críticas al DU 20/2020 que modifica la Ley de Arbitraje. La reserva mental del legislador y lo que realmente se normativizó*. Recuperado de: https://ciarglobal.com/comentarios-y-criticas-al-du-20-2020-que-modifica-la-ley-de-arbitraje/.

Por todo lo expuesto se concluye que el Decreto de Urgencia 020-2020, Decreto de Urgencia que modifica el Decreto Legislativo 1071, Decreto Legislativo que norma el arbitraje, es acorde con la Constitución Política del Perú, y fue aprobado respetando la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. En tal sentido, el decreto de urgencia cumple con los criterios de control aplicables a este tipo de normas durante el interregno.

VI. CONCLUSIÓN

Por lo expuesto, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos concluye en que el Decreto de Urgencia 020-2020, Decreto de Urgencia que modifica el Decreto Legislativo N° 1071, Decreto Legislativo que norma el arbitraje, **CUMPLE** con lo establecido en el segundo párrafo del artículo 135 de la Constitución Política del Perú.

Sala de Comisiones.
Lima, 17 de noviembre de 2021.

61. En tal sentido, es correcto indicar que, como lo hemos dicho anteriormente, el control difuso es exclusiva competencia de los órganos que ejercen función jurisdiccional, por lo que, la revisión de la constitucionalidad de una norma jurídica no es competencia del Congreso de la República, lo cual conlleva a que el dictamen referido no sea vinculante para la decisión que emita el Árbitro de Emergencia al ejercer control difuso respecto del artículo 8° del Decreto de Urgencia N°020-2020.

62. Por el principio de separación de poderes es correcto señalar que el control constitucional que ejerza este Árbitro de Emergencia esté sujeto a las disposiciones constitucionales según las facultades que le concede la Carta Magna en el sentido expuesto anteriormente.

63. En este sentido lo ha establecido el mismo Tribunal Constitucional a través de la STC N°02132-2008-PA/TC, como se puede leer a continuación:

> *Este Tribunal tiene dicho que el control judicial difuso de constitucionalidad de las normas legales es una competencia reconocida a todos los órganos jurisdiccionales para declarar inaplicable una ley, con efectos particulares, en todos aquellos casos en los que aquella resulta manifiestamente incompatible con la Constitución. El control difuso es entonces un poder-deber del juez consustancial a la Constitución del Estado democrático y social de derecho. Conviene siempre recalcar que la Constitución es una auténtica norma jurídica, la Ley Fundamental de la sociedad y del estado, y un derecho directamente aplicable.*

64. Por tanto, este Árbitro de Emergencia realiza control difuso respecto del último párrafo del numeral 2 del artículo 8° del Decreto de Urgencia N°020-2020 disponiendo su inaplicación para el caso particular.

65. Para efectos de mayor ilustración respecto del cumplimiento de los criterios para ejercer control difuso de parte del Árbitro de Emergencia en correspondencia con el precedente María Julia, según se puede apreciar de la siguiente tabla:

PRESUPUESTOS PARA EJERCER CONTROL DIFUSO SEGÚN EL PRECEDENTE MARÍA JULIA	
PRESUPUESTO	**CUMPLIMIENTO**
De la aplicación de la norma depende la validez del laudo arbitral	El Árbitro de Emergencia considera que la aplicación del segundo párrafo del numeral 2 del artículo 8° del Decreto de Urgencia N°020-2020 incide directamente en la validez del Laudo que se emita con posterioridad, incluso, afectando a la propia naturaleza procesal de las medidas cautelares, en cuanto estas tienen como objeto asegurar la eficacia del Laudo.
No es posible obtener una interpretación de la norma conforme a la Constitución	A consideración del Árbitro de Emergencia existe una clara desproporcionalidad en la regulación de las medidas cautelares solicitadas por un privado o por el Estado. Por lo que, esta situación regulada en el último párrafo del numeral 2 del artículo 8° el Decreto de Urgencia N°020-2020 contraviene directamente la Constitución en el extremo de la observancia debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva toda vez que transgrede la igualdad ante la ley. El Árbitro de Emergencia no considera que exista otra forma de interpretación del último párrafo del numeral 2 del artículo 8° del Decreto de Urgencia N°020-2020, siendo que este contraviene abiertamente la Constitución, según lo expuesto anteriormente.
Se verifica la existencia de un perjuicio claro y directo respecto al derecho de alguna de las partes	Existe un perjuicio claro y directo al solicitante en su calidad de contratista solicitante de una medida cautelar en perjuicio de una Entidad del Estado, en atención a tratarse de una medida desproporcionada que afectaría la ejecutabilidad del Laudo Arbitral que, en su oportunidad y según su criterio, emita el Tribunal Arbitral.

66. En ese sentido se deja constancia que el Árbitro de Emergencia **HA CUMPLIDO** con desarrollar, analizar y fundamentar cada uno de los presupuestos

establecidos por el Tribunal Constitucional para el ejercicio del control difuso de parte de los tribunales arbitrales.

E.3.- SOBRE LA GRADUACIÓN DE LA GARANTÍA SOLICITADA COMO CONTRACAUTELA.

67. La contracautela es la *garantía que extiende el solicitante en favor de quien soportará la medida cautelar a efectos de cubrir los daños que, eventualmente, origine la indebida aplicación de la medida cautelar*, es decir, tiene la finalidad, en principio, asegurar el resarcimiento de daños al demandado por el anticipo de tutela a favor del demandante.

68. El otorgamiento de la contracautela se justifica debido a que una medida cautelar siempre se fundamenta en una probabilidad, más no en una certeza, por lo que siempre existe la posibilidad que esta haya sido otorgada quien no le correspondiere el derecho. Considerando, que una medida cautelar siempre implica la restricción de derechos, la contracautela, busca proteger o resarcir los daños generados por una medida cautelar aplicada de forma indebida.

69. Asimismo, la doctrina y la legislación contemplan tres tipos de contracautela, aquellas de naturaleza **real**, **personal** y **juratoria**. Las primeras consisten en la participación de una persona que asegure el resarcimiento de los eventuales daños de la medida (ejemplo, un fiador); la segunda está enfocada al aseguramiento de los mismos mediante un bien mueble o inmueble del Solicitante (ejemplo, embargo con inscripción); y, por último, las de naturaleza juratoria que consiste en la promesa del pago de una suma de dinero si se llegase a generar algún daño de la medida otorgada (ejemplo, caución juratoria).

70. Es una práctica usual en el ámbito procesal el ofrecimiento de garantías de naturaleza juratoria, de hecho, tal como se ha señalado anteriormente, es una garantía cautelar regulada de forma expresa en el tercer párrafo del artículo 613° del Código Procesal Civil peruano, a través del cual se ha indicado que: "*La contracautela puede ser de naturaleza real o personal. Dentro de la segunda se incluye la caución juratoria, la que puede ser admitida, debidamente fundamentada, siempre que sea proporcional y eficaz. Esta forma de contracautela es ofrecida en el escrito que contiene la solicitud de medida cautelar, con legalización de firma ante el secretario respectivo*".

71. Por lo tanto, se reafirma la postura que es un tipo de contracautela legal y acorde al ordenamiento jurídico peruano y a la práctica procesal, misma que cumple la misma finalidad de toda contracautela, la cual es garantizar el derecho de quien soporta la medida cautelar y mantener el equilibrio subsistente entre ambas.

72. Ahora bien, considerando que la caución juratoria, al tratarse de un arbitraje que implica al Estado, requiere de un tratamiento especial, **EL ÁRBITRO DE EMERGENCIA CONSIDERA NECESARIO QUE ESTA SEA OTORGADA A TRAVÉS DE ESCRITURA PÚBLICA**, en cuando es entendido como un documento autorizado por notario público que contiene uno o más actos

jurídicos, de conformidad al artículo 51° de la Ley N°26002 – Ley del notariado. Siempre que con dicha formalidad se garantizaría que el documento sea de fecha cierta y además se encuentre revestido por la fe pública que otorga la realización a través de notario público.

73. De hecho, la Ley del notariado, considera a la escritura pública como un documento de protocolización, según se puede leer de su artículo 25°, concordante con el literal a), de su artículo 37°:

> ***Artículo 25.-*** *Son instrumentos públicos protocolares las escrituras públicas y demás actas que el notario incorpora al protocolo notarial; que debe conservar y expedir los traslados que la ley determina.*

74. En ese sentido, este Árbitro de Emergencia considera necesario protocolizar el presente acto de contracautela a través del instrumento de escritura pública otorgada por notario en atención a revestir el mismo como un documento de fecha cierta y dotado de fe pública.

75. Por otro lado, en torno a la **GRADUACIÓN DEL MONTO** por el que debe ser otorgado la contracautela, el Árbitro Único expone las siguientes consideraciones:

- En primer término, corresponde señalar que no puede ser un monto equivalente al establecido en el Decreto de Urgencia N°020-2020, siempre que dicho monto es equiparable al otorgado en razón a la garantía de fiel cumplimiento, por lo que, dichos intereses ya se encuentran cubiertos en razón a la misma. En ese sentido, la naturaleza que debe tener una contracautela debe ser diferente a la que señalan las garantías ya establecidas en el contrato, por lo cual se descarta la posibilidad que el monto sea fijado por el equivalente a la garantía de fiel cumplimiento.

- Luego, tampoco se puede considerar una contracautela por el monto del contrato, en tanto este monto representa el valor económico de la controversia en arbitraje, así como la inversión del Estado en la ejecución de la obra encomendada al contratista, por lo que, el monto que cautele los intereses del Estado en razón a la dación de la medida cautelar no puede ser equiparable al monto del contrato.

- En consecuencia, el monto fijado como contracautela deber ser un monto que obedezca al valor de los intereses verdaderamente discutidos en el arbitraje, atendiendo a criterios como la naturaleza de la controversia. Esto en razón a que, siendo la controversia la resolución del contrato y tratándose de

un procedimiento que requerirá un análisis especial de parte del Tribunal Arbitral, se puede entender que la complejidad de la controversia aumenta el riesgo de vulnerar los intereses de la Entidad, en caso el Laudo Final no sea favorable al demandante.

- Debe tenerse en consideración que los intereses de la Entidad y el valor que se asigne a los mismos en proporción con la contracautela fijada, inciden directamente en que el objeto del contrato es de alto impacto para la zona en la que se ejecuta la obra, siempre que se trata de un contrato de rehabilitación y mejoramiento de caminos vecinales, afectando directamente a la comunidad beneficiada de la obra ejecutada.

- En razón a estos argumentos, el Árbitro de Emergencia considera proporcional, atendiendo a los fines ulteriores del contrato y la necesidad pública, que la caución juratoria ascienda al monto de cinco (05) veces el valor de la garantía de fiel cumplimiento del Contrato, toda vez que los intereses públicos que socaban la ejecución del contrato deben ser tutelados también por este Árbitro de Emergencia.

76. Asimismo, en atención a la proporcionalidad que obedece a la cuantía discutida en el presente arbitraje, así como la tutela de los intereses de la Entidad, y teniendo en consideración que el fin ulterior del Contrato sub litis se vincula a una necesidad pública que no solo interesa a las partes, sino a toda la comunidad, este Árbitro de Emergencia, considera pertinente que la contracautela sea otorgada por cinco (05) veces el monto de la garantía de fiel cumplimiento del contrato, en atención a la tutela de los intereses del Estado en el caso que el Laudo Final resulte desfavorable para el contratista, por lo cual el monto de esta asciende a la suma de **S/3´085,257.15 (TRES MILLONES OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 15/100 SOLES)**.

77. En ese sentido, dado el elevado monto que el Árbitro de Emergencia considera como contracautela suficiente para garantizar el derecho y los intereses de la Entidad, se concede el plazo de diez (10) días hábiles para que se cumpla con la presentación de esta, mismo que resulta proporcional y equiparable al monto por el cual se solicita el ofrecimiento de la contracautela en forma de caución juratoria.

78. Déjese constancia que la presente decisión no es definitiva, por el contrario, la misma podrá ser revisada por el Tribunal Arbitral a efectos de confirmar, revocar o modificar la misma según estime pertinente.

79. La presente decisión cautelar obedece al estricto criterio del Árbitro de Emergencia fundado en los argumentos expuestos en la presente, mismos que han tomado en consideración la postura de ambas partes, dejándose constancia

que estas han tenido oportunidad de defenderse y expresar sus argumentos en todo momento.

Por las consideraciones expuestas, el Árbitro de Emergencia **RESUELVE:**

PRIMERO: TENER POR PRESENTADO el escrito de vistos (vi) sumillado como "Respuesta a la Carta N°147-2023-SG-CARD-CECARD/AYA", presentado por la **MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TOTOS**, en consecuencia, **PONER EN CONOCIMIENTO** el mismo a la empresa **HYDROCONSULTING INGENIEROS ASOCIADOS S.R.L**.

SEGUNDO: DECLARAR FUNDADO el pedido cautelar solicitado por la empresa **HYDROCONSULTING INGENIEROS ASOCIADOS S.R.L**. referente a ordenar a Mapfre Perú suspenda la ejecución de la carta fianza de garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato emitida en favor de la Entidad. En consecuencia, el Árbitro de Emergencia **ORDENA** a la empresa **MAPFRE PERÚ** que **SUSPENDA** la ejecución de la Carta Fianza N°7102210101293-001 por Fiel Cumplimiento, por el importe de **S/617,051.43 (SEISCIENTOS DIECISIETE MIL CINCUENTA Y UNO CON 43/100 SOLES)**, emitida en favor de la **MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TOTOS** del Contrato N°090-2022-MDT/GM.

TERCERO: DECLARAR INFUNDADO respecto del pedido de medida cautelar referente a ordenar a la Municipalidad distrital de Totos se abstenga de realizar cualquier acto que signifique liquidar la obra, ejecutar el saldo de obra por administración directa o indirecta, mientras dure el arbitraje.

CUARTO: ORDENAR a la empresa **HYDROCONSULTING INGENIEROS ASOCIADOS S.R.L**. la presentación de una caución juratoria en calidad de contracautela en favor de la **MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TOTOS** por el monto de **S/3´085,257.15 (TRES MILLONES OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 15/100 SOLES)** equivalente a cinco (05) veces el monto de la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato sub litis, mismo que deberá ser alcanzado en escritura pública a la Secretaría General de la institución arbitral para su custodia en el **PLAZO DE DIEZ (10) DÍAS HÁBILES**, computados a partir del día hábil siguiente de notificada la presente Resolución, bajo apercibimiento de revocar la medida cautelar concedido en su favor.

QUINTO: PRECISAR que una vez presentada la contracautela indicada esta quedará en custodia de la institución arbitral Centro de Arbitraje y Resolución de Disputas – CECARD hasta la emisión del Laudo Final que resolverá las controversias derivadas del Contrato N°090-2022-MDT/GM. A su vez, será puesta en conocimiento de la **MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TOTOS** y del Árbitro de Emergencia, a efectos de dar cuenta del cumplimiento de este mandato.

SEXTO: PRECISAR que la empresa **HYDROCONSULTING INGENIEROS ASOCIADOS S.R.L**. debe mantener vigente la garantía de fiel cumplimiento del Contrato N°090-2022-MDT/GM, hasta la finalización del arbitraje, pudiendo ser ejecutada por la Entidad cuando esta no sea renovada, bajo su responsabilidad.

<u>SÉPTIMO</u>: ORDENAR la empresa **HYDROCONSULTING INGENIEROS ASOCIADOS S.R.L**. que, en el **PLAZO PERENTORIO DE TREINTA (30) DÍAS HÁBILES**, contados a partir del día siguiente de notificada la presente resolución, cumpla con presentar la respectiva Solicitud de Arbitraje correspondiente a resolver las controversias sobre la resolución del Contrato N°090-2022-MDT/GM, bajo apercibimiento de declarar la caducidad de la medida cautelar de emergencia dictada en la presente resolución; de conformidad al artículo 4° de las Reglas de Árbitro de Emergencia del Centro de Arbitraje y Resolución de Disputas – CECARD.

<u>OCTAVO</u>: PRECISAR que la presente resolución no amerita un análisis definitivo sobre el fondo de la controversia materia de litis siempre que esta deberá ser discutida en el Tribunal Arbitral que resulte competente para dicha función.

<u>NOVENO</u>: DÉJESE CONSTANCIA que la presente decisión no es definitiva y que podrá ser revisada por el Tribunal Arbitral a efectos de confirmar, revocar o modificar la misma según estime pertinente.

<u>DÉCIMO</u>: NOTIFICAR a las partes 'involucradas en este procedimiento arbitral según corresponda.

La presente Resolución se emite con la revisión y aprobación del **ÁRBITRO DE EMERGENCIA**: CARLOS ENRIQUE ALVAREZ SOLIS. –

CARLOS ENRIQUE ALVAREZ SOLIS
ÁRBITRO DE EMERGENCIA